

1502099-44.2022.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do réu, estaria traficando drogas no local em que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o acusado ter sido flagrado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502099-44.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502099-44.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra Marcos Felipe Martins dos Santos, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, c.c 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (fls. 183/187).

O réu foi devidamente notificado, apresentando resposta escrita às fls. 192/193.

Denúncia recebida em 04 de novembro de 2022, conforme decisão de fls. 198/199.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 2 testemunhas arroladas pela acusação e 6 testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o representante do Ministério Público e o defensora apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprido ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, "o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do autor do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o denunciado explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do réu, estaria traficando drogas no local em que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o acusado ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o acusado ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o autor do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls.26), pelo auto de avaliação (fls. 20), pelo laudo pericial (fls. 80/87) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 15h05, na Rua Lúcia de Carly Ribeiro de Barros, 1721, - Jardim Pevi, , nesta cidade e comarca, Penápolis, o denunciado MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS, vulgo "Sapinho", nas imediações de estabelecimento de ensino, guardava, para posterior entrega e consumo de terceiro, 28 (vinte e oito) porções da substância popularmente conhecida como cocaína, na forma de "crack", pesando 9,71 gramas (conforme laudo de constatação de fls. 80/83 e definitivo de fls.152/154), bem como 09 (nove) porções da substância popularmente conhecida como cocaína pesando 2,05 gramas (conforme laudo de constatação de fls. 84/87 e definitivo de fls.149/151), o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento, quando foram abordados por pais de alunos da Escola Municipal Elza Nadai, os quais noticiaram que um indivíduo conhecido como "Sapinho", que havia saído há pouco tempo da cadeia e que residia nas proximidades do colégio (a cerca de duas quadras, no numeral 1721), estaria vendendo drogas naquele momento, em sua residência. Diante de tal informação, os policiais para lá se dirigiram e visualizaram o denunciado em frente à sua casa.

Realizada a abordagem, fora realizada revista pessoal, sendo localizada, nos bolsos da blusa de frio do increpado, a quantia de R\$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais) em notas diversas, bem como um aparelho celular da marca Samsung, na cor preta, em funcionamento. Indagado, o denunciado disse que o dinheiro encontrado era oriundo do auxílio governamental de sua esposa Aline. Confirmou, ainda, que havia drogas em sua casa destinadas tanto para o uso pessoal, quanto para o tráfico. Franqueada a entrada dos agentes públicos na residência, MARCOS FELIPE apontou aos PM's onde guardava as substâncias entorpecentes, sendo, então, localizado, sobre o rack da sala, um invólucro azul de ferro contendo em seu interior 28 (vinte e oito) porções de substância amarelada conhecidas como "crack", envoltas em papel alumínio. Foram encontradas, também, mais 9 (nove) porções de substância branca da substância conhecida como "cocaína", embaladas em sacola plástica de cor branca. Em prosseguimento às buscas, os policiais localizaram, em cima da pia da cozinha, um rolo de papel alumínio parcialmente consumido.

Indagado, MARCOS FELIPE confessou aos agentes públicos que vendia drogas em sua casa e que parte do dinheiro localizado com ele, em verdade, era oriundo de venda de drogas, não sabendo informar a quantidade exata. Disse, ainda, que a cocaína era destinada a seu consumo pessoal e que o crack iria vender por 10 reais, cada unidade.

Importante ressaltar que a casa onde ocorreu a abordagem e a prisão do denunciado fica a 75,40m da Escola Municipal Elza Nadai (fls.55), que estava em funcionamento naquele momento.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fls. 19).

As substâncias apreendidas foram periciadas, sendo constatada sua natureza entorpecente, "cocaína", conforme laudos de constatação de fls. 80/83 e 84/87 e definitivos de fls.152/154 e 149/151). O rolo de papel alumínio encontrado na residência do increpado também foi periciado e o laudo juntado aos autos às fls. 155/159.

Assim, a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos evidenciam que MARCOS FELIPE guardava as porções de cocaína para posterior entrega a consumo de terceiros, fazendo-o nas imediações de unidade escolar.

A imputação feita na denúncia foi confirmada pela prova oral colhida ao longo da persecução penal. Vejamos.

O acusado Marcos Felipe Martins dos Santos, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "Possui apelido de "Sapinho". Sua esposa Aline está ciente da prisão e entende desnecessário avisar outros parentes. Não tem queixas a respeito do procedimento dos policiais. Não está machucado e sua integridade psicológica também está preservada. Tem uma filha de nove anos, que não é deficiente, e sua esposa está gestante no momento. A respeito das imputações, deseja se manifestar apenas em Juízo e com assistência de advogado. Tem passagens por roubos, furtos e receptação. Ficou aproximadamente onze anos preso" (sic) (fl. 19).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado Marcos Felipe Martins dos Santos negou a autoria delitiva. Sustentou que no dia dos fatos havia ido até o Centro da cidade com sua esposa para que ela recebesse o benefício do Auxílio Brasil. O depoente foi se deitar e, pouco tempo depois, um policial entrou em sua casa, dizendo que havia denúncia de que o interrogado estaria vendendo drogas no local. Negou ao policial que fosse traficante, explicando que era usuário. O policial o acusou de tráfico, porém a droga era para o seu uso, e não para venda. É usuário de maconha e cocaína. O crack apreendido era para o consumo da mãe do interrogado. Em momento algum confessou aos policiais que estivesse traficando.

As testemunhas Igor Jose de Oliveira e Bruno Prado de Oliveira, policiais militares, em solo policial, disseram que "por volta das 15h00 foram abordados por pais de alunos da Escola Municipal Elza Nadai informando que um indivíduo conhecido como "Sapinho", residente duas quadras abaixo, no numeral 1721, baixo, branco e com tatuagens, que havia saído há pouco tempo da cadeia, estaria vendendo drogas naquele momento em sua residência. Diante das informações recebidas, foram até o citado local e se depararam com pessoa informada de frente ao imóvel. Foi abordado e identificado o suspeito como sendo MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS, o qual confirmou possui apelido de "Sapinho". Em revista pessoal foram localizados nos bolsos da blusa de frio a quantia de R\$ 667,00 em notas diversas e um aparelho celular da marca Samsung, na cor preta, e em funcionamento. Indagado a respeito do dinheiro, Marcos alegou que seria oriundo do auxílio governamental de sua esposa Aline. Cientificado das denúncias contra si formuladas por munícipes, Marcos de imediato confessou ter drogas em sua residência para venda e uso e ressaltou que sua esposa não participaria da traficância. Foi franqueado o acesso ao interior do imóvel e Marcos mesmo indicou onde estariam as substâncias. Foi localizada em cima de um rack na sala um invólucro azul de ferro com imagem de desenho animado contendo em seu interior 28 porções de substância amarelada com aspecto de "crack", envoltas em papel alumínio, além de 9 porções de substância branca com aspecto de "cocaína", embaladas em sacola plástica de cor branca. Em prosseguimento às buscas, localizaram em cima da pia um rolo de papel alumínio parcialmente consumido. Questionado novamente, Marcos confirmou vender drogas em sua residência e então ressaltou que parte do dinheiro localizado em verdade era oriundo de venda de drogas, não sabendo informar a quantidade exata. Marcos explicou que a "cocaína" tinha para consumo pessoal e que o "crack" tinha para vender por 10 reais cada unidade. No quintal do imóvel foi localizada uma bicicleta de cor original verde, repintada na cor preta, com número de quadro "NF11123588"; questionado, Marcos alegou ter adquirido de uma vizinha, conhecida como "Bia", na data de ontem, porém não informou valor, tampouco apresentou nota fiscal. Diante desse cenário, foi dada voz de prisão a Marcos e após lidos os direitos constitucionais ele foi conduzido até as dependências do 01 DP Penápolis, com uso de algemas em virtude do receio de fuga e para preservação da integridade física dos envolvidos na ocorrência. Marcos não está com lesões e cooperou com a diligência. A esposa de Marcos, Aline, compareceu no local e depois veio até a Delpol. Não conhecia Marcos dos meios, pois ele ficou aproximadamente 11 anos preso e saiu há pouco da cadeia. Em pesquisas foi verificado que Marcos possui mandado de prisão em aberto por roubo, oriundo da Comarca de Pirapozinho, e anotações policiais por crimes diversos. Quer consignar, por fim, que o local da abordagem e encontro de drogas fica a menos de 100 metros da creche do Bairro Pevi e Escola Municipal Elza Nadai, centros estudantis que nesta data estavam em funcionamento e são frequentados por crianças" (sic) (fls. 08/11 - grifo meu).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Igor Jose de Oliveira e Bruno Prado de Oliveira sustentaram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando, ao passarem pela Escola municipal Elza Nadai, alguns pais de aluno abordaram a equipe policial para denunciar que um indivíduo, de alcunha SAPINHO, com baixa estatura, de cor branca e tatuagens, estaria vendendo drogas em frente a um imóvel situado duas quadras abaixo. Deslocaram-se até o referido imóvel e se depararam com o réu, que tinha as características narradas pelos denunciante. Encontraram em poder do acusado dinheiro em espécie, trocado em cédulas diversas, bem como um aparelho celular. O acusado disse que o dinheiro seria proveniente de um auxílio governamental recebido pela esposa dele. O réu confirmou que havia drogas no imóvel para seu uso e para a venda para terceiros. Ingressaram na sala do imóvel e apreenderam as drogas em um pote azul de metal, que foi indicado pelo denunciado. O réu disse que a cocaína seria para o uso dele e que o crack seria para venda. Também localizaram um rolo de papel alumínio parcialmente usado e utilizado para embalar drogas. A esposa do acusado chegou ao local depois. Questionado, o denunciado disse que a esposa não era traficante. Também havia uma bicicleta repintada no quintal. Indagado sobre a bicicleta (pois usuários furtam bicicletas para trocar por drogas), o acusado disse que a teria adquirido de uma

vizinha, porém ele não apresentou nota da compra. Indagado a respeito da distância entre a residência do réu e a escola municipal, o depoente IGOR esclareceu que fica a aproximadamente um quarteirão de distância. Esclareceu, ainda, que a referida escola, bem como uma creche, estavam em funcionamento no momento da abordagem, tanto é assim que os pais dos alunos denunciaram o réu pela traficância. Os depoentes afirmaram que não conheciam o réu, que permaneceu muitos anos preso. A denúncia não dizia que o réu vendia drogas na escola municipal, mas sim defronte à residência dele. Não foi feita campana em frente à casa do réu, pois o acusado havia saído da prisão há pouco tempo. O réu confessou ser traficante. Não presenciaram o denunciado entregar drogas para terceiros.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha KALINE BARBOSA DOS SANTOS narrou que é enteada do réu. Presenciou o momento da prisão do réu. Sua mãe havia recebido Auxílio Brasil. Quando eles chegaram em casa, a polícia o abordou e prendeu o denunciado. O réu é usuário de drogas. Os policiais acharam drogas no local. A droga era da mãe dele, que também é usuária. Ele guardava as drogas para a mãe dele. Depoente mora com o réu e com a mãe da depoente. Nunca viu movimentação de venda de drogas nas imediações. Nunca viu o réu usando drogas. Sua mãe é usuária de drogas. Conhece o réu desde que ele se casou com sua mãe, há pouco mais de um ano. Ele trabalha com bicos na área rural e como pedreiro. Sua mãe se chama ALINE BARBOSA DOS SANTOS.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha ALINE BARBOSA DOS SANTOS narrou que é companheira do réu. Presenciou o momento da prisão do réu. Tinham acabado de chegar do centro. A depoente foi receber o Auxílio Brasil. A viatura estava parada em frente à casa do vizinho. Um policial veio até o portão e perguntou à depoente se era a companheira do réu. Entrou na casa com sua filha e viu o réu algemado. O policial pegou os celulares da depoente e da sua filha, bem como o dinheiro do Auxílio Brasil. O celular de sua filha foi restituído. O crack é da sua sogra, que é usuária. A cocaína era de seu marido, ora acusado, que também é usuário.

Guardavam dinheiro em casa para pagar o vício de sua sogra. Somente havia drogas no pote. Não foram encontradas drogas em outros cômodos da casa. Nunca presenciou venda de drogas nas imediações de sua casa. Seu marido, ora acusado, não vendia drogas na parte de fora da residência do casal. Escutou a conversa de seu marido com a polícia. Ele disse aos policiais que a cocaína era destinada para o uso da depoente e dele e que o crack era destinado ao uso de sua sogra. Ele não falou aos policiais que era traficante. O papel alumínio era usado para embalar comida. A bicicleta que estava no quintal do imóvel foi vendida por sua vizinha. Sua vizinha não sabia que a bicicleta era produto de crime. O réu já respondeu a outros processos criminais. Em nenhum deles o réu foi processado ou condenado por tráfico.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha BEATRIZ AQUILINO MEIRA narrou que é vizinha do acusado MARCOS. Presenciou o momento da prisão do réu. O acusado estava dentro de casa quando a polícia chegou. Ele saiu de casa algemado. Nunca viu movimentação de venda de drogas em frente à casa do réu. O denunciado é usuário de drogas. Já viu o réu usando drogas nos finais de semana. Reside no local há pouco mais de 2 anos e nunca viu o réu vendendo drogas. O acusado trabalha com bicos como encanador e mecânico.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a testemunha do fato, sentindo-se amedrontada e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco detalhe a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao magistrado. Em tal contexto, a denúncia anônima e o depoimento de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

Registre-se que a testemunha 6, arroladas pela defesa, (não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a reproduzir a versão do denunciado) (não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a tecer considerações a

respeito da conduta social do acusado) (possuem vínculo de amizade com o acusado) (possuem vínculo de parentesco com o acusado) (disseram ter interesse na absolvição do denunciado). Por essa razão, tais declarações, por si sós, são insuficientes para afastar a materialidade e a autoria delitivas.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralde, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida - 9,71 gramas de cocaína, na forma de crack, dividida em 28 porções; e 2,05 gramas de cocaína, dividida em 9 porções - e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do denunciado de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) a existência de denúncia feita pelos pais de uma escola estadual relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e alcunha do réu, estaria traficando drogas em frente a um imóvel situado a duas quadras de distância da Escola Municipal Nadai; b) o fato de o acusado ter sido flagrado por policiais exatamente no local apontado como ponto de venda de entorpecentes; c) a apreensão, em poder do acusado, de dinheiro em espécie, fracionado em notas miúdas, não tendo o denunciado oferecido explicação convincente para a origem do numerário (não se apresentou a comprovação de que o referido montante de fato fosse oriundo do benefício Auxílio Brasil); d) a apreensão de apetrecho relacionado ao tráfico (parte de um rolo de alumínio para embalar drogas).

7. A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Não há como acolher o pleito defensivo.

Estabelece o artigo 40 da Lei de Drogas que "As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos" (grifo meu).

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...] A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 1.028.605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018 - grifo meu).

Em suma, para a incidência da causa de aumento de pena do inciso III, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/2006, "é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (HC n. 450.926/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018 - grifo meu).

Esse é o caso dos autos.

Com efeito, restou demonstrado que o acusado guardava entorpecentes, para posterior entrega a consumo de terceiros, em sua residência, situada nas imediações de um estabelecimento de ensino.

De acordo com as provas colhidas durante a persecução penal, policiais militares em patrulhamento foram abordados por pais de alunos da Escola Municipal Elza Nadai, os quais noticiaram que um indivíduo com a alcunha "SAPINHO" estaria vendendo drogas, naquele instante, em sua residência, situada há apenas duas quadras do estabelecimento de ensino. Os agentes públicos deslocaram-se até o imóvel e visualizam o réu em frente à sua casa, encontrando em seu poder dinheiro em espécie. Localizaram, ainda, várias porções de drogas prontas para serem comercializadas para terceiros.

Destarte, de rigor o reconhecimento da majorante em questão.

8. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº

11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa. In casu, verifico que o acusado é reincidente (0007564-55.2015.826.0438) e possui maus antecedentes (processos n.º 0000108-25.2013.8.26.0438; 0011341-58.2009.8.26.0438).

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0000108-25.2013.8.26.0438; 0011341-58.2009.8.26.0438.

Considerando-se que o acusado ostenta 2 condenações definitivas que não configuram reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dia-multa

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo

Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.
Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0007564-55.2015.826.0438), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como os maus antecedentes e a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi

contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 793 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA